

1520208-57.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520208-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520208-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240170/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27165342 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2240170 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DOS SANTOS DIOGO DE FARIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JEFFERSON DOS SANTOS DIOGO DE FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 01 de setembro de 2022, por volta das 17h30, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo a substância Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 135,1 gramas (cento e trinta e cinco gramas e um decigrama), 68 (sessenta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 22,4 gramas (vinte e dois gramas e quatro decigramas), 11

(onze) invólucros plásticos contendo "crack", com massa líquida de 10,5 gramas (dez gramas e cinco decigramas), todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Em 16 de setembro de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação de defesa preliminar (fls. 68/70). O réu foi notificado (fls. 92) e ofertou defesa preliminar às fls. 104/105, arrolando as mesmas testemunhas da acusação. A denúncia foi recebida (fls. 109/110) e o réu foi devidamente citado (fls. 117/118).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo, em seguida, o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a fixação no mínimo legal, incidência da agravante da reincidência, que não fosse aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 § 4º da Lei nº 11.343/2006, que as penas fossem aumentadas em razão da reincidência do réu.

Pleiteou ainda e o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

O Defensor nomeado sustentou pela absolvição por insuficiência de provas e pela ilicitude na obtenção da prova. Pediu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência do redutor, com a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu na via pública, ao celular, em local que fica perto de pontos de tráfico, sendo que o policial José Henrique afirmou que naquele local costumeiramente ficam olheiros. Como o réu demonstrou nervosismo, decidiram retornar para efetuar abordagem. Deram ordem de parada, sendo que ele levantou as mãos, mas quando foram desembarcar das motos, ele começou a correr. Partiram em seu encalço, sendo que o policial José Henrique seguiu à frente. Ambos notaram que o réu tinha um volume na cintura. Em dado momento da fuga, José Henrique viu que o réu dispensou um objeto ao chão. Continuaram na perseguição até que lograram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Acionaram o apoio e em varredura, no local onde José Henrique viu o réu dispensando um objeto, foi encontrada uma sacola, dentro da qual havia diversos tipos de droga em porções fracionadas. Junto à sacola havia o aparelho celular. O policial Alessandro chegou a perder o réu de vista durante a perseguição e não presenciou o momento em que ele dispensou o objeto, mas afirmou que quando ele foi abordado não mais tinha um volume na cintura. Alessandro afirmou que a sacola foi encontrada em um local em que o réu fez uma espécie de retorno, ao redor de um carro e de uma caçamba. Não o conheciam anteriormente. José Henrique disse que o réu afirmou que alguém havia deixado com ele aquela sacola por um momento, sem dar maiores detalhes. Alessandro não manteve contato verbal com o réu. Ninguém interveio em favor dele durante a abordagem. Ele disse que era morador de área livre naquela região. José Henrique disse que ele não parecia estar sob efeito de drogas e que com ele havia um canudo de alumínio comumente utilizado para consumo de crack. Alessandro não se recordava de qualquer apetrecho para consumo de drogas.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas e prontas para a entrega a usuários; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a condição financeira do réu; ausência de demonstração que a droga destinava-se para seu consumo próprio; o réu foi visto inicialmente em local muito próximo de pontos de tráfico; as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo que os policiais decidiram dar ordem de parada ao réu após ele ter demonstrado nervosismo, quando falava ao telefone,

sendo que ao levantar as mãos, o réu saiu correndo no momento em que os policiais desembarcaram das motos; os policiais notaram, durante a perseguição, que o réu tinha um volume na cintura, sendo que o policial José Henrique viu o momento em que o réu dispensou um objeto ao chão durante a fuga, local em que posteriormente foi encontrada a sacola com drogas.

Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Considera-se que a abordagem policial levada a cabo nestes autos seja regular e não esteja de qualquer forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente descritos pelos policiais ouvidos indicam que havia fundada suspeita a ensejar a revista pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Ora, os policiais narraram que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, disseram que ao receber ordem de parada o réu inicialmente demonstrou que a obedeceria, mas quando os policiais desembarcavam de suas motos ele iniciou fuga a pé, durante a qual observaram que ele tinha um volume na cintura, tendo sido presenciado pelo policial José Henrique o momento em que ele dispensou um objeto ao chão. Assim, tais elementos viabilizavam, concretamente, a revista pessoal que foi feita ao réu. A ordem de parada emanada inicialmente não está maculada, já que o legislador impede a revista pessoal sem a fundada suspeita e não a abordagem em si. Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observo que pequenas contradições, não essenciais aos fatos, apenas ratificam a veracidade de seus depoimentos, pois indicam de forma clara que não houve prévio ajuste sobre a versão que deveria ser ofertada, baseando-se seus relatos

exclusivamente na memória que têm do dia dos fatos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 86/88, que atestou positivamente para cocaína e tetrahydrocannabinol (THC), além do auto de exibição e apreensão (fls. 13).

Irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido comercializando os entorpecentes, pois se trata de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração, sendo que no presente caso trazia consigo e guardava, as drogas supramencionadas.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a despeito da natureza nociva de um dos entorpecentes encontrados em seu poder, entende-se que a quantidade não seja suficiente para representar maior mácula ao bem jurídico tutelado, motivo pelo qual a pena-base é ora fixada no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias atenuantes. O réu é reincidente pela 21ª Vara Criminal Central – autos nº 1513369-50.2021.8.26.0228 – trânsito em julgado para a defesa em 10/08/2021 – fls. 28/29, de modo que majoro sua pena em nova fração de 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente. Com efeito, o legislador não estabeleceu que apenas a reincidência específica é capaz de afastar a incidência de causa de diminuição de pena, sendo certo que conceito de reincidência é objetivo e legalmente previsto.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, trata-se de réu reincidente, em atual cumprimento de pena (fls. 28) e, ainda, a gravidade em concreto do delito em questão, justifica o regime fechado, tendo em conta a relevante diversidade dos entorpecentes apreendidos, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o réu JEFFERSON DOS SANTOS DIOGO DE FARIAS, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de penas ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Ademais, trata-se de réu reincidente, o qual estava em cumprimento de pena quando da prática do delito apurado no presente feito (fls. 28), a indicar que sua liberdade seja um risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 109/110.

Oficie-se para destruição do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA